

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 1/3) em face de PAULO SÉRGIO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, supostamente, em 08/04/2019, por volta das 09hrs30min, na Avenida Mário Pinotti, nº 656, Jardim Civitas, na cidade e comarca de Brotas/SP, o acusado teria subtraído para si R\$5.000,00 em espécie da vítima Regina Zambon Cláudio.

Narra a exordial acusatória que o acusado visualizou a vítima segurando a sacola plástica que continha o montante em dinheiro e, ao notar que Eliane seguiu desacompanhada e a pé em direção ao banco Santander, deliberou abordá-la. Assim, objetivando tirar a atenção da vítima para o pacote que carregava, o denunciado perguntou-lhe as horas e, aproveitando-se da distração de Eliane enquanto pegava o celular, tomou a sacola e entrou em um automóvel VW/Fusca, empreendendo fuga. Em sequência, o denunciado comprou um telefone celular em loja da Vivo na cidade de Torrinha/SP, sendo essa compra realizada em dinheiro em espécie. A atendente, suspeitando das atitudes de Paulo, contatou a polícia e, com isso, fora descoberto que Paulo se encontrava em saída provisória, bem como esse afirma ter recebido os valores que portava após sair da penitenciária. Contudo, o MP entende que não há elementos suficientes para manutenção da prisão preventiva, requerendo assim, a revogação dessa.

Auto de prisão em flagrante (fls. 4/5).

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 48).

Revogação de prisão preventiva e recebimento da denúncia em 23/04/2019 (fls. 82/83).

Mandado de prisão às fls. 91/93.

Alvará de soltura às fls. 96/99

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 124/125).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento para a data de 26/10/2022 às 16:00 (fls. 139/140).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a absolvição. A Defesa, igualmente, pediu a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida, conforme estabelecem os tribunais superiores:

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...) "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos). (grifos nossos)

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse".

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais do que suficientes para atestar a consumação.

Feitas essas considerações, no caso em análise, foram comprovadas a materialidade do crime e de sua autoria.

A existência do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelos termos de declarações de fls. 19, relatório final (fls. 77/78) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

No que concerne à autoria, contudo, entendo que foi comprovado que o réu Paulo Sérgio da Silva não concorreu para a prática da infração penal, impondo-se a absolvição.

A vítima Eliane Regina Zambon Cláudio, em juízo, teve seu depoimento dispensado pelas partes.

A testemunha Vilson Dias de Castro, policial militar, em juízo, teve seu depoimento dispensado pelas partes.

A testemunha Edmar Carneiro Boldan, policial militar, em juízo, disse que a funcionária da loja da vivo falou que o indivíduo entrou lá e queria fazer pagamento a vista, tirando muito dinheiro do bolso; que ela ligou no 190 porque não era um ato comum; que chegando ao local pegaram os dados e conseguiram o nome do Paulo; que Paulo confirmou ter feito a compra do aparelho celular; que questionaram a origem do dinheiro; que verificaram as características dele e a vítima confirmou; que a funcionária da loja da vivo falou que ele estava em um veículo branco; que o furto foi em Brotas na parte da manhã; que à tarde, essa moça da loja da Vivo em Torrinha disse que estranhou ele tirar uma grande quantia de dinheiro do bolso; que ele foi abordado na residência dele em Torrinha; que, questionado sobre o furto, ele negou; que sobre o dinheiro, ele disse que recebeu na penitenciária; que a vítima, no momento, havia reconhecido; que na Delegacia, foi mostrada só uma foto do Paulo.

A testemunha Jéssica Rodrigues Marche, em juízo, teve seu depoimento dispensado pelas partes.

Paulo Sérgio da Silva, em juízo, disse que recebeu o dinheiro do trabalho que prestou no presídio; que não veio para Brotas; que ficou em Torrinha; que comprou um celular na vivo lá em Torrinha; que foi apreendido pela polícia; que deu o próprio CPF; que pagou certinho e deu seu RG; que estava a pé na casa do seu pai; que estava com todo o dinheiro no bolso.

De fato, não há como condenar o réu pelo crime descrito na denúncia. Desde o início, o réu negou os fatos, dizendo que os valores que possuía foram recebidos por serviço prestado na penitenciária onde se encontrava detido. Ademais, a autoridade policial da Delegacia de Polícia de Brotas, ao contatar o Diretor da Penitenciária de Porto Feliz, foi informada que o acusado realmente recebeu o valor de R\$4.200,00 em decorrência dos trabalhos desempenhados no presídio.

Inclusive, segundo consta no inquérito policial, na data de 11/04/2019, a vítima compareceu na unidade policial de forma espontânea, manifestando desejo em ser ouvida novamente para retificar sua oitiva anterior no tocante ao reconhecimento de PAULO SÉRGIO. Alegou que após os fatos, com a cabeça mais fria, rememorando os fatos, passou a ter dúvidas se PAULO SÉRGIO DA SILVA foi realmente o autor do furto.

Além disso, deve-se consignar que não houve reconhecimento pessoal em delegacia nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, tampouco em juízo, mas apenas reconhecimento fotográfico após análise e alegações de "familiaridade" pela vítima, o que não se pode admitir como meio de prova, na ausência de outros indícios ou elementos probatórios a corroborá-lo.

Nessa linha, é importante mencionar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, conduzido por um paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS

CORPUS Nº 598.886 – SC, julgado em 27.10.2020), no qual afirma que “o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva.”.

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e

não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). (...)

12. Conclusões:

- 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
- 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
- 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
- 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (grifos nossos).

Assim, por essas razões, deve o acusado Paulo Sérgio da Silva ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado PAULO SERGIO DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/carta precatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Comunique-se à vítima acerca desta sentença (CPP, art. 201, § 2º).

Determino, desde logo, a restituição do dinheiro e do celular apreendidos ao acusado.

Expeça-se o necessário.

Sentença registrada eletronicamente.

Saem os presentes intimados.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Brotas, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA